

1500645-23.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... réu admitiu que estava praticando o tráfico. No interior da pochete havia drogas diversas. Disse que quando ele jogou a pochete, as drogas se espalharam. Recolheu as drogas. Localizou também dinheiro e anotações de drogas. Questionado, disse que a Travessa Amazonas tem cerca de 300 metros, e a localização em que o tráfico é praticado varia.

Observe-se que o depoimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500645-23.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500645-23.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090170/2022 - 03º D.P.

DIADEMA, 2090170 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michell Gabriel da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos,

MICHELL GABRIEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 1.º/04/2022, o acusado trazia consigo e guardava, para o consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 84 embalagens plásticas contendo 59,21g da droga cocaína, 193 embalagens plásticas contendo 17,84g da mesma droga, na forma de crack, e 15 embalagens plásticas contendo 24,13g da droga maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica. O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 74/76.

O réu foi regularmente notificado (fls. 88), tendo apresentado defesa preliminar a fls. 92/94. A denúncia foi recebida a fls. 96/97, e o réu foi regularmente citado. Na audiência de instrução debates e julgamento foi colhida a prova oral. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, nos termos do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, pelo mérito a presente ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 74/76, que atestou positivo para as substâncias entorpecentes tetrahydrocannabinol (THC – maconha) e cocaína, substâncias estas consideradas ilícitas pela Portaria 344/1998 SVS/MS. Consigno que a perícia não foi contestada pela defesa.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo. É certo que de acordo com o art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado afirmaram, em sede policial, que patrulhavam pela Travessa Amazonas quando avistaram um indivíduo, identificado como MICHELL GABRIEL DA SILVA, que trazia consigo segurando com as mãos um estojo e, ao notar a presença policial correu e tentou jogar o estojo em cima de um telhado, mas foi detido e, recolhido o estojo que ele trazia consigo, verificaram que em seu interior havia 15 invólucros contendo substância semelhante a maconha, 84 invólucros contendo substância semelhante a cocaína e 193 invólucros contendo substância semelhante a crack, além de anotações num papel e R\$ 134,00; que, indagado, MICHELL disse que vendia droga no local; que proferiram voz de prisão em flagrante a MICHELL GABRIEL DA SILVA e o conduziram ao Distrito Policial. Em juízo, a testemunha Gustavo Tadeu Teixeira, policial militar, afirmou que no dia dos fatos estava realizando uma operação na região dos fatos, inclusive com outras equipes fechando as saídas. Disse que visualizou o acusado na posse de uma pochete, e quando ele avistou o depoente, jogou a pochete em cima de um telhado. A pochete foi apreendida. O réu admitiu que estava praticando o tráfico. No interior da pochete havia drogas diversas. Disse que quando ele jogou a pochete, as drogas se espalharam. Recolheu as drogas. Localizou também dinheiro e anotações de drogas. Questionado, disse que a Travessa Amazonas tem cerca de 300 metros, e a localização em que o tráfico é praticado varia.

Observe-se que o depoimento prestado em juízo por este policial, além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àqueles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a este depoimento. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de esta testemunha ser policial, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, sobretudo porque seu depoimento está amparado em outros elementos de convicção.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n.º 74.608-SP – STF).

Em juízo o acusado confessou integralmente os fatos. Disse que tentou correr, mas foi abordado pelos policiais. Confirmou que era ele quem estava vendendo as drogas. Ora, o local em que ocorreu a prisão (conhecido ponto de tráfico de drogas), a forma como estava embalada a droga, a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, o encontro de dinheiro e a observação prévia feita pelos policiais são indicativos do intuito de traficância. Por outro lado, pela própria

quantidade e demais circunstâncias, não há como desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistirem pacificamente em uma única pessoa.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1.<sup>a</sup> T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p. 11.012).

Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade.

Ressalto que o argumento de que o acusado praticou o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão.

Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu:

"Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.<sup>a</sup> Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

É o que basta para a caracterização do(s) delito(s).

Comprovada, assim, a autoria e a materialidade do delito. Impõe-se, nestes termos, a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, seguindo os critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, deve ser considerada como circunstância judicial preponderante desfavorável a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, dentre elas a cocaína, substância que notoriamente vulnera de forma mais intensa o bem jurídico protegido – qual seja, a saúde pública –, causando maior grau de dependência do que outras drogas ilícitas, como a maconha. Anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.<sup>a</sup> ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286, grifei). Significa dizer que o legislador explicitou, no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que já deveriam ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59, do Código Penal, transformando-as em preponderantes.

Desta forma, a pena base deve ser agravada em 1/6, sendo fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo, considerando as condições econômicas do réu.

Na segunda fase da dosimetria, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão efetuada pelo réu. Em razão disso, aplico a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd' do CP e reduzo as penas em 1/6. Faço a pena tornar ao mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/06. De acordo com entendimento amplamente majoritário do E. Supremo Tribunal Federal, "a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa" (HC n.º 124.107/SP, Primeira Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe

de 24/11/14; HC n.º 122.626/SP, Primeira Turma, rel. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14; RHC n.º 118.008/SP, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/13; HC n.º 108.388/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/13; Recurso Ordinário em HC n.º 116.049, rel. Dias Toffoli; HC n.º 111.309/DF, rel. Ministro Roberto Barroso).

No caso em tela, anoto que as circunstâncias não indicam que o acusado tenha envolvimento de forma reiterada ou profissional com a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida. De fato, não há provas seguras de que o réu já praticava a traficância anteriormente, de modo que cabível a redução, no percentual de 2/3.

Assim, por força da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena fixada na fração de 2/3, o que resulta em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, na forma especificada. A minguia de outras circunstâncias que pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva. No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do habeas corpus n.º 111.840-ES (Informativo STF n.º 507), ser inconstitucional a fixação obrigatória de regime inicial fechado, consoante dispõe o § 1.º, art. 2.º, da Lei n.º 8.072/90, com as alterações decorrentes da Lei n.º 11.464/07. Assim, de acordo com referido precedente, compete ao juiz, analisadas as especificidades do caso concreto, fixar o regime inicial de cumprimento de acordo com as disposições do art. 33, do Código Penal.

Este mesmo entendimento deve ser aplicado no caso em tela, quer pela chamada "objetivação do controle difuso" (tese adotada e aplicada pelo E. Supremo Tribunal Federal), quer em sede de controle difuso de constitucionalidade por este Magistrado, declarando-se a inconstitucionalidade, incidenter tantum, do dispositivo legal em comento. De fato, a fixação a priori, pelo legislador, de um regime inicial de cumprimento, sem permitir que o Magistrado possa aferir, no caso concreto, qual o regime mais adequado para o sentenciado, com análise dos requisitos objetivos e subjetivos, fere o princípio implícito da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5.º da CF/88). Partindo desta premissa, passo a fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Considerando a quantidade de pena fixada (inferior a 04 anos), a primariedade do agente, bem como o tempo da prisão preventiva, fixo o regime inicial aberto, por entender, diante destas circunstâncias, ser este regime suficiente para fins de reprovação e prevenção da conduta a ele imputada.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar MICHELL GABRIEL DA SILVA qualificado nos autos, à pena 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Fixo, desde logo, as seguintes condições para cumprimento da pena em regime aberto (art. 115, da Lei n.º 7.210/84):

- (a) permanecer em sua residência durante o repouso e nos dias de folga;
- (b) sair para apenas para tratamento médico, estudo ou trabalho, retornando ao término do expediente;
- (c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;
- (d) comparecimento periódico em Juízo (em prazo a ser fixado no Juízo da Execução Criminal), para informar e justificar as suas atividades.
- (e) Não frequentar determinados lugares, a saber: pontos de venda de drogas ("biqueiras"), locais e eventos em que sejam oferecidas ao público, de forma gratuita ou onerosa, bebidas alcoólicas para consumo imediato (bares, bailes, festas, "baladas" e congêneres).

Considerando os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em casos assemelhados, a Resolução n.º 05, do Senado Federal, bem como a presença das condições legais para tanto (art. 44, do Código Penal), substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma na modalidade prestação de serviços à comunidade (art.

43, inciso IV, do CP), e outra na modalidade prestação pecuniária (art. 43, inciso I, do CP), eis que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, na forma do artigo 44, § 2.º, do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros, na forma do artigo 46 do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução na forma do artigo 149 da LEP. As tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, até que venha a totalizar a pena imposta, na forma do artigo 46, § 3.º, do Código Penal.

Já a prestação pecuniária, que fixo no mínimo legal de 01 (um) salário mínimo, consiste no pagamento de dinheiro a entidade pública ou privada de destinação social, a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Considerando a quantidade de pena aplicada e o regime inicial de seu cumprimento, bem como a ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, na forma do artigo 4.º, § 9.º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da Assistência Judiciária. Proceda-se à destruição das drogas, na forma do art. 72, da Lei n.º 11.343/2006. Decreto a perda dos valores apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do FUNAD/SENAD.

Transitada em julgado:

a) expeça-se certidão da sentença para fins de execução da pena de multa (artigos 479-A e 480, das NSCGJ), bem como guia de execução definitiva, e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

Não havendo interesse na preservação do bem apreendido (pedaço de folha de caderno, contendo anotações; porta lápis - estojo, conforme auto de apreensão de fl. 22), e considerando a ausência de valor econômico, autorizo sua destruição.

Expeça-se o necessário.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Diadema, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA